DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 09-2023-LPG-CECARD/ARBITRAJE DE EMERGENCIA/ AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje de Emergencia.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio Vial Ayacucho.

Demandado : Municipalidad Distrital de Anchihuay.

ARBITRO DE EMERGENCIA : Abg. Luis Puglianini Guerra.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

PEDIDO CAUTELAR : Medida Cautelar de No Innovar y otros.

FECHA DE INICIO : 05 de mayo de 2023.

FECHA DE CONCLUSION : 15 de mayo de 2023.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

ARBITRAJE N° 09-2023-LPG-CARD-CECARD/AYA

CONSORCIO VIAL AYACUCHO
(en adelante, el Contratista o el Consorcio)

vs.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY
(en adelante, la Entidad o la Municipalidad)

RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE EMERGENCIA

Árbitro de Emergencia
Luis Puglianini Guerra

EXP. N° 09-2023-LPG-CARD-CECARD/AYA

Ayacucho, 15 de mayo de 2023.

DEMANDANTE: **CONSORCIO VIAL AYACUCHO**
DEMANDADO: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY**

RESOLUCIÓN CAUTELAR N° 02

VISTOS:

a. Escrito de fecha 05 de mayo de 2023 presentado por el CONSORCIO, con sumilla "SOLICITA ARBITRAJE DE EMERGENCIA Y PIDE TUTELA CAUTELAR".

b. Escrito de fecha 12 de mayo de 2023, presentado por la ENTIDAD, con sumilla "Formula oposición a medida cautelar por ser contrario a Ley de Contrataciones y Ley de Arbitraje".

c. Escrito de fecha 12 de mayo de 2023 presentado por el CONSORCIO, con sumilla "COMUNICO RIESGO DE EJECUCION DE POLIZA DE CAUCION No. 0001959-5 POR PARTE DE CRECER SEGUROS".

ATENDIENDO:

1. Mediante escrito del 05 de mayo de 2023, el Consorcio solicitó al Centro de Arbitraje el inicio de un arbitraje de emergencia y la emisión de una medida cautelar.

2. El pedido cautelar del Consorcio consiste en lo siguiente:

> *En protección del legitimo derecho del CONSORCIO VIAL AYACUCHO, al amparo del inciso a) del artículo 63 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje, aprobado mediante Decreto legislativo 1071; SOLICITAMOS DICTE MEDIDA CUATELAR CONSISTENTE EN: ORDENAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY SE ABSTENGA A EJECUTAR:*
>
> *(i) La **POLIZA DE CAUCION No. 0001959-5**, emitida por CRECER SEGUROS, por el importe de S/. 1'333,052.60 (un millón trecientos treinta y tres mil cincuenta y dos con 60/100 soles) que garantiza la entrega del adelanto de materiales derivado del CONTRATO No. 0326-2020-MD.ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA.*
>
> *(ii) Solicitamos además que <u>los efectos de la orden cautelar se extiendan a</u> CRECER SEGUROS, con domicilio en Av. Jorge Basadre 310 – piso 02 – San Isidro – Lima - Peru; **<u>ORDENANDO</u>** se abstenga y/o rechace cualquier requerimiento y/o solicitud por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY destinada a ejecutar La **POLIZA DE CAUCION No. 0001959-5.***

En consecuencia, se curse la documentación correspondiente a la municipalidad demandada y a CRECER SEGUROS a fin que cumplan con el mandato impuesto.

3. Al respecto, el Árbitro Único pese al pedido formulado para que la medida cautelar sea dictada sin conocimiento de la parte contraria *-in audita altera pars-*, en salvaguarda del derecho de contradicción de la Entidad no encontrando fundamento y prueba algún que permita evidenciar la necesidad de no poner en conocimiento a la otra parte y que ello afectaría el efecto de la medida, por lo que el Árbitro Único decidió conferir traslado del pedido cautelar; la Entidad absolvió el pedido cautelar mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2023.

4. El Árbitro Único deja constancia que la Entidad formuló una oposición a la medida cautelar urgente, mediante la cual se indica que el pedido de medida cautelar urgente a través de una Corte Internacional de Arbitraje es ilegal ya que la ley de arbitraje peruana no existe la figura de la medida cautelar urgente.

5. Finalmente, con fecha 23 de mayo de 2023, el CONSORCIO presentó un escrito informando que la aseguradora CRECER SEGUROS comunicó que el lunes 15 se estaría procedimiento a la ejecución de la caución 1959-5.

Y CONSIDERANDO:

6. Que, las facultades de los árbitros para dictar medidas cautelares se encuentran expresamente señaladas en una norma con rango de Ley, como es el Decreto Legislativo N° 1071, más específicamente en el Artículo 47° del citado texto legal;

7. Que, el numeral 1) del artículo 47° del Decreto Legislativo N° 1071 establece que: "*Una vez constituido, el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las* medidas *cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la medida*".

8. Que, asimismo, en este caso resulta aplicable los reglamentos de arbitraje del Centro, donde se incluye la posibilidad de solicitar un arbitraje de emergencia para pedir una medida cautelar previa a constitución del Tribunal Arbitral que conocerá el fondo del arbitraje.

9. Que, de lo argumentado por el Consorcio, se observa que la medida pretendida se refiere, tal como se ha mencionado en los antecedentes, en disponer que se ordene a la Entidad que se abstenga de ejecutar la **POLIZA DE CAUCION No. 0001959-5,** emitida por CRECER SEGUROS, por el importe de S/. 1'333,052.60 (un millón trecientos treinta y tres mil cincuenta y dos con 60/100 soles) que garantiza la entrega del adelanto de materiales derivado del CONTRATO No. 0326-2020-

MD.ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA, lo cual es concordante con lo establecido en el literal a) del numeral 2) del artículo 47° del Decreto Legislativo N° 1071.

10. Que, el Consorcio fundamenta la solicitud de su medida cautelar en:

2. PRESUPUESTOS PARA LA PRESENTE SOLICITUD (LEGITIMIDAD E INTERÉS PARA OBRAR)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47° inciso del Decreto Legislativo N° 1071 (Decretos Legislativo que norma el Arbitraje), **e invocando la necesidad de tutela urgente** de nuestros derechos, solicitamos al Tribunal Arbitral Unipersonal con carácter de URGENTE, dicte MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR, con el objeto de que el demandado, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY, SE ABSTENGA de ejecutar la POLIZA DE CAUCIÓN N° 00001959-5, que garantiza el adelanto de materiales, derivado del CONTRATO N° 0326-2020- MD.ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA.

3. PRETENSIÓN CAUTELAR

En protección del legítimo derecho del CONSORCIO VIAL AYACUCHO, al amparo del inciso a) del artículo 63° del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje - CECARD y el artículo 47° del Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo 1071; **SOLICITAMOS DICTE MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN:** ORDENAR A la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY SE ABSTENGA A EJECUTAR:

y Resolución de Disputas - CECARD

i. La POLIZA DE CAUCIÓN N° 00001959-5, emitida por CRECER SEGUROS, por el importe de S/. 1'333,052.60 (un millón trecientos treinta y tres mil cincuenta y dos con 60/100 soles) que garantiza la entrega del adelanto de materiales derivado del CONTRATO N° 0326-2020- MD.ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA.

ii. Solicitamos además que los efectos de la orden cautelar se extiendan a CRECER SEGUROS, con domicilio en Av. Jorge Basadre 310 – piso 02 - San Isidro – Lima – Perú: ORDENANDO se abstenga y/o rechace cualquier requerimiento y/o solicitud por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY destinada a ejecutar la POLIZA DE CAUCIÓN N° 00001959-5.

En consecuencia, se curse la documentación correspondiente a la municipalidad demandada y a CRECER SEGUROS a fin que cumplan con el mandato impuesto.

4. PRETENSIONES DE LA FUTURA DEMANDA ARBITRAL

Siendo que, la petición cautelar invocada tiene una naturaleza extra procesal, y además, en nuestro sistema jurídico las medidas cautelares tienen un carácter instrumental; es necesario señalar que se iniciará un proceso arbitral que tendrá como objeto las siguientes pretensiones:

A. PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Que el Tribunal Arbitral DECLARE LA INEFICACIA de la Resolución del CONTRATO N° 0326-2020- MD. ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA, efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY, contenida en la Resolución de Alcaldía N° 062-2023-MDA/A de fecha 06FEB2023.

B. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL

Que el Tribunal Arbitral ORDENE a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY asumir los gastos que irrogue la organización y tramitación del arbitraje de emergencia y el arbitraje en su trámite regular, incluyendo los honorarios arbitrales, gastos administrativos, así como la asesoría técnica y legal.

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PRETENSIÓN

Fundamentamos nuestra pretensión cautelar en lo dispuesto por el artículo 63° del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje - CECARD, que señala:

> "Artículo 63°. - Medida cautelar emitida por Árbitro de Emergencia
>
> 1. Hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes que requiere medida cautelar urgente puede solicitar que se inicie un procedimiento ante un árbitro de emergencia, quien conoce y resuelve la respectiva solicitud.
>
> 2. Las decisiones adoptadas por el Árbitro de Emergencia son vinculantes para las partes, quienes, por el hecho de haber sometido la controversia a arbitraje bajo el Reglamento, se obligan a cumplirlas sin demora..."

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 47° del Decreto Legislativo 1071, que señala:

> "1. Una vez constituido, el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la medida.
> 2. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo que resuelva definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordena a una de las partes:
>
> a. *Que mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se resuelva la controversia;*
>
> b. *Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al proceso arbitral;*
>
> c. *Que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo subsiguiente; o*
>
> d. *Que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia."*

6. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL

De conformidad con la Cláusula Vigésima: Solución de Controversias del CONTRATO N° 0326-2020- MD. ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA, se ha señalado:

"Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación y arbitraje, según acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

7. FUNDAMENTOS DEL PEDIDO CAUTELAR

ANTECEDENTES

7.1 Con fecha 31DIC2020, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY y el CONSORCIO VIAL AYACUCHO (en adelante el CONSORCIO), suscribieron el CONTRATO N° 0326-2020- MD. ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA para la contratación de EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE BUENA GANA-MARAYNIYOQ, DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY, PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO, derivado de la Licitación Pública N° 005-2020-MDA.

7.2. Dentro del marco de la ejecución del contrato la citada entidad mediante una decisión arbitraria ha determinado la resolución del contrato antes mencionado, la misma ha sido sometida a la vía del procedimiento conciliatorio, en la que se viene teniendo avances sustanciales respecto a la controversia de resolución de contrato, cuya fundamentación es evidentemente ilegal y arbitraria; a saber, se tiene en el extremo resolutivo lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 326-2020-MD.ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA entre la Municipalidad Distrital de Anchihuay con RUC N° 20574738866 y el **CONSORCIO VIAL AYACUCHO** para la Ejecución de la Obra **"CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL BUENA GANA – MARAYNIYOQ, DISTRITO DE ANCHIHUAY-LA MAR-AYACUCHO"**, con CUI N°2309900, por el monto de S/ 10.870,316.20 (DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 20/100 SOLES). Por las siguientes causales estabiecidas en el articulo 164 del Reglamento y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del estado y en concordancia al literal **a)** Si el contratista incumple con sus obligaciones contractuales **b)** Si el contratista no cumple con realizar el aporte del saldo de los adelantos pendientes de amortizar a los que se refiere el literal c) del numeral 7.3.2 de la Directiva. **c)** Si el contratista retira de la obra: personal, equipo o materiales sin autorización del Inspector o supervisor de Obra. Numeral 7.4.1 de la Directiva N°013-2019-OSCE/CD.; acogiendo lo establecido en cada uno de los informes Técnicos y legales que forman

7.3. Sin embargo, consideramos que la Entidad ha incurrido en un error al interpretar con sesgo la normativa de contrataciones del Estado que regula específicamente el procedimiento de resolución de contrato, cuyo texto normativo establece claramente qué: *Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante* **carta notarial** *que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.*

> *Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.*
> *Si vencido dicho plazo el incumplimiento continuo, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.*
> *(...)*

7.4. En el presente caso, la Entidad ha transgredido deliberadamente el procedimiento establecido para la resolución de contrato, haciendo entrever que su propósito es únicamente causarnos perjuicio y de modo sucedáneo al órgano usuario y con ello también causar una grave afectación a la finalidad publica de la contratación; esto es, la arbitraria e injustificada resolución de contrato, dará lugar a que la obra que ha sido esperado por tanto tiempo por las localidades de Marayniyoq y Buena Gana no podrá concluirse en su oportunidad.

No obstante, al solamente requerirnos con una carta simple y no con la formalidad prevista; se advierte una clara y manifiesta transgresión al procedimiento establecido por la normativa glosada en líneas precedentes.

En efecto, **la norma establece que, el requerimiento es notarial y así mismo el apercibimiento debe ser expreso, no se sobre entiende**; situación que no ha cumplido la Entidad, por consiguiente, deviene en nulo e ineficaz la Resolución de Alcaldía N° 062-2023-MDA/A de fecha 06FEB2023.

7.5. No obstante, la resolución del contrato, puesta a controversia pese a que mi representada ha venido ejecutando la prestación, no delimita si es la totalidad o de modo parcial, situación que debe ser cumplida por disposición de los acápites 165.3 y 165.5 del Art. 165° del Reglamento. Máxime si, están debidamente acreditados que mi representada ha desplegado toda acción en cumplimiento de la ejecución de la obra, situación que ha merecido desembolso de fondos e inversión, **por lo que la supuesta y negada resolución debió ser parcial**; empero que la entidad en su afán de causar perjuicios a mi representada ha vulnerado las disposiciones legales antes referidas.

7.6. Por lo demás, la motivación del acto mediante el cual de manera injustificada y arbitraria ha determinado resolver el contrato, se encuentra constituida por contenido subjetivo, pese que las disposiciones normativas únicamente prevén como posibilidad la resolución contractual y no como un mandato imperativo que debe ser cumplida, para tal efecto previamente se debe evaluar de manera adecuada las ventajas o desventajas de tal determinación.

8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PEDIDO CAUTELAR

VEROSIMILITUD DEL DERECHO

8.1. La verosimilitud del derecho o fumus boni iuri comprende la apariencia certidumbre que reviste el derecho invocado y que será materia de un pronunciamiento definitivo, cuya ejecución debe ser salvaguardada.

La verosimilitud del derecho, en las medidas cautelares de no innovar, se vinculan al ámbito de lo hipotético y lo razonablemente posible; esto es, un nivel de cognición de posibilidad más que de probabilidad.

8.2. En este sentido, se tiene que **el derecho que se invoca**, es que **LA RESOLUCIÓN DEL** CONTRATO N° 0326-2020- MD. ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA (efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY, contenida en la Resolución de Alcaldía N° 062-2023-MDA/A de fecha 06FEB2023), **NO SE HA EFECTUADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL RLCE, esto es, no es acorde a derecho, y por lo tanto, no debe generar efectos jurídicos.**

8.3. En el caso en particular, la Resolución del CONTRATO N° 0326-2020- MD. ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA, tiene como fundamento el incumplimiento de obligaciones por parte del CONTRATISTA.

Al respecto, esta causal de resolución del contrato, que se encuentra establecida en el artículo 165° del RLCE, requiere para su configuración, la existencia de un requerimiento previo, mediante el cual se exija el cumplimiento de la obligación, en el plazo de 15 días y bajo apercibimiento de resolver el contrato, lo que **no ha sucedido en el presente caso, por lo que, la Resolución del Contrato efectuada por la ENTIDAD contraviene el RLCE.**

8.4. No obstante, debió ser parcial atendiendo a la ejecución de prestaciones por parte de mi representada; esto es las razones por las cuales la Resolución del Contrato efectuada por la ENTIDAD no debe generar efectos jurídicos (es decir, se debe declarar su ineficacia); es necesario precisar que uno de estos efectos jurídicos es precisamente la ejecución de la garantía de adelanto de materiales.

Es precisamente este efecto el que se busca evitar con la tutela cautelar que se solicita, pues al haberse resuelto el contrato sin observar los preceptos establecidos en el RLCE, no debe generar efectos jurídicos.

8.5. En el presente caso, la Resolución del CONTRATO N° 0326-2020- MD. ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA, efectuada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY, AUN NO SE HA CONSENTIDO; y precisamente se viene impulsado la posibilidad de conciliar lo que hace inoficioso la ejecución de la Póliza de caución que garantiza la entrega de adelanto de materiales.

PELIGRO EN LA DEMORA Y PERJUICIO IRREPARABLE

8.6. Siendo que, la POLIZA DE CAUCIÓN N° 00001959-5, emitida por CRECER SEGUROS, por el importe de S/. 1'333,052.60 (un millón trecientos treinta y tres mil cincuenta y dos con 60/100 soles), tiene una naturaleza incondicional, irrevocable, indivisible y de realización automática; esta puede ser ejecutada por la ENTIDAD en cualquier momento. Por lo tanto, el peligro tiene como principal fundamento la posibilidad que tiene la ENTIDAD de ejecutar la POLIZA DE CAUCIÓN N° 00001959-5, a pesar de que la resolución del contrato no sea acorde a derecho, se estaría materializando palmariamente un abuso de derecho.

Es necesario precisar también, que la doctrina nacional establece que el perjuicio invocado en las medidas cautelares de no innovar, exige un grado de posibilidad en su configuración; esto es, un peligro fundado y razonable, que no necesita ser cierto e inminente.

8.7. Asimismo, de conformidad con el artículo 687° del Código Procesal Civil, "Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es excepcional por lo que se concederá sólo cuando no resuelve de aplicación otra vista en la ley."

En este sentido, es necesario la configuración de un perjuicio irreparable y además inminente, que en el presente caso es concreto; pues, tenemos de conocimiento que, la ENTIDAD ha requerido a CRECER SEGUROS la ejecución de la POLIZA DE CAUCIÓN N° 00001959-5; y, siendo esta fianza incondicional, es inminente su ejecución.

PROPORCIONALIDAD Y ADECUACIÓN DE LA MEDIDA

8.8. La medida cautelar de no innovar tiene como objeto mantener la situación de hecho y de derecho de la POLIZA DE CAUCIÓN N° 00001959-5 que garantiza la entrega de adelanto de materiales derivado del CONTRATO N° 0326-2020- MD.ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA, mediante su no ejecución.

Entonces, la finalidad que se busca salvaguardar es el patrimonio del CONSORCIO que se verá afectado ante la ejecución de la POLIZA DE CAUCIÓN N° 00001959-5; y, el medio por el cual se pretende este resguardo, es mediante la medida cautelar de no innovar.

En este sentido, **la medida cautelar de no innovar es la más adecuada**, pues busca mantener la situación de hecho y de derecho de la POLIZA DE CAUCIÓN N° 00001959-5, con la finalidad de que esta no sea ejecutada y genere un perjuicio al CONSORCIO.

Asimismo, **no existe otra medida que cumpla esta finalidad**, pues la medida de no innovar es la única que, por su naturaleza, busca mantener el status de hecho y de derecho, hasta la emisión de una decisión que resuelva la controversia jurídica.

Finalmente, realizando **una ponderación** entre el derecho cuya tutela se busca, y el derecho de la ENTIDAD, esta última no se verá afectada, pues el pedido cautelar de no ejecutar la POLIZA DE CAUCIÓN N° 00001959-5, comprende a su vez mantener la vigencia de estas; es decir, la ENTIDAD no se vería afectada, pues seguiría teniendo afianzado o garantizado su derecho.

9. CONTRA CAUTELA

9.1 A efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 60° y 64° del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje - CECARD, ofrecemos **contracautela en la forma de Caución Juratoria de cuantía indeterminada.** Sin embargo, dejamos a criterio del Tribunal la decisión de exigir otra contracautela en la forma que estime adecuada.

9.2. En lo que concierne a la reciente modificatoria al numeral 2 del artículo 8° de la Ley de Arbitraje por medio del Decreto de Urgencia No. 20-2020 (en adelante, el "DU 20-2020"), incluyendo un segundo párrafo a dicho artículo, el cual establece que, en los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada, por el tiempo que dure el proceso arbitral precisándose que el monto de la garantía no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento, manifestamos lo siguiente:

i. A propósito del dictado del DU 20-2020, se tendría como exigencia normativa la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial por un monto no menor a la garantía de fiel cumplimiento del Contrato, lo que implica que, en términos sencillos, la Entidad tendría una doble garantía y se estaría condicionando al Consorcio la concesión de la medida cautelar solicitada.

ii. El Tribunal Constitucional ha establecido que "(...) la igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2° de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: "[...] toda persona tiene derecho [...] a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole". Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, se está frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino en ser tratadas del mismo modo que quienes se encuentran en una idéntica situación".[1]

iii. Asimismo, el derecho a la igualdad tiene dos expresiones: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la ley debe ser aplicable, por igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de hecho de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.

iv. Por lo que, **por mandato constitucional las normas deben ser aplicables por igual**, el solo hecho de que la Entidad, que es parte del Estado peruano, sea parte en una **relación contractual,** más allá de las prerrogativas que ya tiene por mandato de la Ley de Contrataciones del Estado, no implica que se tenga que admitir como válida una exigencia legal que desconoce el elemental principio de igualdad reconocido constitucionalmente.

v. De otro lado, como se puede apreciar de la Exposición de Motivos del DU 20-2020, se afirma que existe una "abusiva" utilización de las medidas cautelares por parte de los Consorcios, cuyo otorgamiento genera consecuencias negativas para el Estado, por ejemplo, paralización de la ejecución de obras, afectación en la prestación de servicios públicos, etc.

En el presente caso, ninguna de las medidas cautelares solicitadas podría ser entendida como "abusiva", **sino todo lo contrario, es la Entidad quien está actuando con total abuso y arbitrariedad hacia la empresa.**

En relación al derecho de la empresa a la tutela jurisdiccional efectiva, el Tribunal Constitucional ha establecido que "(...) la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual foda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia"[2].

En el presente caso, es fundamental que el Árbitro de emergencia tenga en consideración que esta solicitud de medida cautelar se realiza en ejercicio de nuestro derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, que se encuentra reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política vigente, y que dicho derecho debe prevalecer por sobre una traba ilegal tal como la establecida por el DU 20-2020.

9.3. Por las razones expuestas, al vulnerarse derechos constitucionales tales como el de igualdad y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, rogamos al Árbitro de emergencia que, en el marco del reconocimiento establecido en el precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 142-2011-PA/TC, hacer control difuso y establecer que no corresponde exigir para el caso concreto la fianza bancaria y/o patrimonial señalada en la norma que se inaplica (modificatoria al numeral 2 del artículo 8° de la Ley de Arbitraje por medio del DU 20-2020).

11. Que, la posición de la Entidad es la siguiente:

- **Escrito presentado el 12 de mayo de 2023**

  - **Oposición de la medida cautelar urgente:**

II. FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR URGENTE:

2.1. En principio, la parte accionante Consorcio Vial Ayacucho, solicita al Árbitro de Emergencia, se tramite Medida Cautelar sin conocimiento de la Entidad, para que mi representada: "*Abstenerse de ejecutar la póliza de Caución Nro. 00001959-5, emitida por CRECER SEGUROS, por el importe de S/ 1'333,052.60 (Un millón trescientos treinta y tres mil cincuenta y dos con 60/100 soles) que garantiza la entrega del adelanto de materiales derivado del Contrato Nro. 0326-2020-MD.ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA*".

2.2. Al respecto señor Árbitro, es necesario referir que el pedido de la parte accionante, es lesivo al debido proceso, derecho a la defensa y derecho a la Igualdad y un claro amparo al ejercicio abusivo del derecho, ya que al pretender aplicar artículo 29° del Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje, esta constituye una violación del artículo 47° del D.L. N° 1071 - Decreto Legislativo que norma el Arbitraje; Artículo 155 del D.S 344-2018-ef reglamento de la ley de contrataciones del estado al vulnerar lo siguiente:

Principio de Territorialidad

- Se estaría transgrediendo el artículo 1 del D.L. N° 1071 que expresa taxativamente que: "*1. El presente Decreto Legislativo se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio peruano, sea el arbitraje de carácter nacional o internacional;(...)*".
- Al aplicar la medida cautelar de emergencia con base normativa en el Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje incurre en total irregularidad e ilegalidad, ya que la norma con la que se debe ceñir cualquier centro de arbitraje es en la ley de arbitraje peruano y en dicha legislación no existe la figura de medida cautelar urgente por tanto aplicar normas ajenas a la nuestra constituye en un ejercicio

- **Absolución de la solicitud de medida cautelar urgente:**

Legalidad de la ejecución de la Póliza de Caución N° 00001959-5 emitida por CRECER SEGUROS por el importe de S/ 1'333,052.60 soles

2.3. Con respecto a la Ejecución de Garantía de Adelanto Directo de Materiales de la Ejecución de la obra "*Creación de camino vecinal Buena Gana – Marayniyoq, del Distrito de Anchihuay – Provincia de La Mar – Departamento de Ayacucho*", con CUI 2309900, por el CONSORCIO VIAL AYACUCHO, se tiene que las fechas de vencimiento de las garantías presentadas por el CONSORCIO VIAL AYACUCHO se encuentra vigente pero adportas de vencerse en 8 días conforme al siguiente cuadro:

ENTIDAD FINANCIERA	N° CARTA FIANZA	MONTO S/	FECHA DE VIGENCIA		OBSERVACIÓN
			DESDE	HASTA	
CRECER SEGUROS	00001955-5	1,333,052.80	19/02/2023	20/05/2023	Vigente

Se debe precisar que el contrato de la ejecución de la obra fue resuelto mediante **Resolución de Alcaldía N° 062-2023-MDA/**A, de fecha 06 de febrero de 2023, la que se notificó al Contratista "CONSORCIO VIAL AYACUCHO" con CARTA NOTARIAL N° 006-2023-MDA/GM de fecha de recepción 07 de marzo del 2023, con el cual conforme a ley se ha requerido el pago del saldo por amortizar del adelanto de materiales por un monto de S/ 1,286,136.00 soles, bajo apercibimiento de la ejecución de la carta fianza, en el cual se le otorga 10 días hábiles,

CLAUDIO BANICO PEREZ DNI N° 28599356 ALCALDE

2.4. Sin embargo, **hasta la fecha no amortizó el adelanto de materiales y ya ha transcurrido 24 días hábiles**, por lo que corresponde la Ejecución de la Garantía por Adelanto Directo de Materiales, conforme al Literal d) del numeral 155.1 del artículo 155º del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, con respecto a la Ejecución de Garantías establéce que "*La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se realice la amortización o el pago,* ***aun cuando este evento haya sido***

Roberto Carrión Quispe ABOGADO C.A.A. N° 1235

sometido a un medio de solución de controversias", así mismo el numeral 155.2 establece que *"En cualquiera de los supuestos contemplados en el numeral anterior, la Entidad en forma previa a la ejecución de la garantía por adelantos, requiere notarialmente al contratista, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que devuelva el monto pendiente de amortizar,* ***bajo apercibimiento de ejecutar la garantía por adelantos por dicho monto".***

2.5. Aunado a ello, el numeral 155.3 del artículo 155º del mismo marco normativo establece que *"Los supuestos previstos en los numerales anteriores están referidos exclusivamente a la actuación de la Entidad, siendo de su única y exclusiva responsabilidad evaluar en qué supuesto habilitador se encuentra para la ejecución de la garantía, por lo que no afectan de modo alguno al carácter automático de tal ejecución y por tanto, de la obligación de pago a cargo de las empresas emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley, al solo y primer requerimiento de la respectiva Entidad, sin poder solicitar que se acredite el supuesto habilitador, sin oponer excusión alguna y sin solicitar sustento ni documentación alguna y en el plazo perentorio de tres (3) días hábiles. Cualquier pacto en contrario contenido en la garantía emitida es nulo de pleno derecho y se considera no puesto, sin afectar la eficacia de la garantía extendida"*, al cual en el numeral 155.4 del mismo marco normativo dispone que *"Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS".*

2.6. En consecuencia, con la debida observancia de la normativa vigente y en vista que han transcurrido ya el plazo que se ha otorgado al CONSORCIO VIAL AYACUCHO para que realice el pago del saldo por amortizar del Adelanto Directo de Materiales y a la fecha no ha cumplido con dicho pago, dado que conforme a la norma que precisa que **no es excusa que el evento haya sido sometido a conciliación o arbitraje ya que ello no lo exime de dicho pago**, por lo que, **la Resolución Cautelar N° 01 no puede entorpecer el ejercicio legítimo de un derecho, en este caso, EJECUCIÓN DE GARANTÍA POR ADELANTO DIRECTO** de Materiales otorgado por la aseguradora

CRECER SEGUROS con PÓLIZA DE CAUCIÓN Nº 00001955-5 por el monto de S/ 1,333,052.80 (Un Millón Trescientos treinta y tres Mil Cincuenta y dos con 80/100).

Consecuencias de no ejecutar la Póliza de Caución N° 00001959-5 emitida por CRECER SEGUROS por el importe de S/ 1'333,052.60 soles carta fianza

2.7. Las graves consecuencias de no ejecutarse el título valor referido en líneas precedentes traerá lo siguiente:

- Primer agravio, que dentro de 8 días vencerá y el dinero que no se ejecute por una medida cautelar ilegal acarreará la responsabilidad del árbitro de emergencia.
- Se estaría afectando el principio de legalidad del arbitraje que aun siendo de emergencia tiene la obligación de adoptar sus decisiones basado en las leyes de la materia por ser de derecho, y no estaría dentro de dichos estándares una decisión que vulnera las normas antes mencionadas.

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:

3.1. Artículo 139° incisos 3) y 14) de la Constitución Política.

3.2. Artículo 1° del DECRETO LEGISLATIVO N° 1071 - Decreto Legislativo que norma el Arbitraje:

*"**Artículo 1.- Ámbito de aplicación.***

1. El presente Decreto Legislativo se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio peruano, sea el arbitraje de carácter nacional o internacional; sin perjuicio de lo establecido en tratados o acuerdos internacionales de los que el Perú sea parte o en leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje, en cuyo caso las normas de este Decreto Legislativo serán de aplicación supletoria.

2. Las normas contenidas en los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 8, en los artículos 13, 14, 16, 45, numeral 4 del artículo 48, 74, 75, 76, 77 y 78 de este Decreto Legislativo, se aplicarán aun cuando el lugar del arbitraje se halle fuera del Perú."

3.3. Inciso 1 y 3 del artículo 47° del DECRETO LEGISLATIVO N° 1071 - Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

"***Artículo 47.- Medidas cautelares.***

1. *Una vez constituido, el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la medida.*

2. *Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo que resuelva definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordena a una de las partes:"*

3.4. El numeral 155.1, 155.2, 155.3 y 155.4 del artículo 155º del DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado:

"***155.1.*** *La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se realice la amortización o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de solución de controversias".*

"***155.2.*** *En cualquiera de los supuestos contemplados en el numeral anterior, la Entidad en forma previa a la ejecución de la garantía por adelantos, requiere notarialmente al contratista, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que devuelva el monto pendiente de amortizar, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía por adelantos por dicho monto".*

"***155.3.*** *Los supuestos previstos en los numerales anteriores están referidos exclusivamente a la actuación de la Entidad, siendo de su única y exclusiva responsabilidad evaluar en qué supuesto habilitador se encuentra para la ejecución de la garantía, por lo que no afectan de modo alguno al carácter automático de tal ejecución y por tanto, de la obligación de pago a cargo de las empresas emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley, al solo y primer requerimiento de la respectiva Entidad, sin poder solicitar que se acredite el supuesto habilitador, sin oponer excusión alguna y sin solicitar sustento ni documentación*

alguna y en el plazo perentorio de tres (3) días hábiles. Cualquier pacto en contrario contenido en la garantía emitida es nulo de pleno derecho y se considera no puesto, sin afectar la eficacia de la garantía extendida"

*"**155.4.** Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS"*

12. La posición del Árbitro Único

I. RESPECTO DE LA OPOSICIÓN FORMULADA EN CONTRA DE LA MEDIDA CAUTELAR

1. De acuerdo a la Entidad, el pedido del Consorcio es lesivo al debido proceso, derecho a la defensa y derecho a la igualdad y en un claro amparo del ejercicio abusivo del derecho al aplicar el art. 29 del Reglamento de Arbitraje de la Corte internacional de Arbitraje, siendo una violación al art. 47 del D.L. 1071 que norma el arbitraje y el art. 155 del D.S. 344-2018-EF – reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

2. En primer lugar, la Entidad indica que se estaría infringiendo el art. 01 del D.L. 1071 que indica que dicha norma se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio peruano, sea el arbitraje de carácter nacional o internacional.

3. En ese sentido, para la Entidad, al aplicar la medida cautelar de emergencia con base a la normativa en el "arbitraje de la corte internacional de Arbitraje" incurre en total irregularidad e ilegalidad, ya que la norma con la que se debe ceñir cualquier centro de arbitraje es la ley de arbitraje peruana y en dicha norma no existe la figura de la medida cautelar urgente.

4. Ahora bien, el Árbitro Único procede a pronunciarse sobre la oposición formulada por la Entidad sin correr traslado al Consorcio considerando los siguientes fundamentos que motivan su decisión:

    a. El Árbitro de Emergencia es competente para conocer la solicitud cautelar y las partes están obligadas a cumplir con las Resoluciones que se emitan.
    b. Naturaleza de emergencia de la solicitud cautelar presentada por el Consorcio.
    c. Inminente riesgo de ejecución de la garantía informado mediante escrito del 12 de mayo de 2023.
    d. Un análisis de proporcionalidad del derecho a la contradicción.

Centro de Conciliación y Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

a. <u>El Árbitro de Emergencia es competente para conocer de la petición cautelar de emergencia</u>

5. El Árbitro de Emergencia confirma su competencia para conocer de la petición cautelar de emergencia de acuerdo a los siguientes fundamentos que motivan el presente pronunciamiento.

6. En primer lugar, de la revisión de la Cláusula Arbitral prevista en la cláusula vigésima del Contrato 326-2020-MD.ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA, no se advierte la existencia de un pacto al tipo de arbitraje o incluso a una institución arbitral.

> **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
>
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
>
> El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

7. Sobre el particular, ante este tipo de cláusulas, la Ley de Arbitraje peruana (DL. 1071 modificada por el DU 20-2020) ha dispuesto que, cuando las partes no pacten el tipo de arbitraje y el Estado sea parte de la controversia, el arbitraje será institucional por regla general.

> **Artículo 7.- Arbitraje ad hoc e institucional.**
> 5. Cuando el Estado peruano interviene como parte, el arbitraje es institucional, pudiendo ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere las diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT). En ambos casos son arbitrajes de derecho; con excepción de los proyectos desarrollados mediante Asociación Público Privada, cuando sus controversias son de naturaleza técnica que pueden ser atendidas alternativamente por arbitrajes de conciencia.

8. Cabe resaltar que, en el presente caso, no puede considerarse que el arbitraje sea ad hoc, toda vez que el monto de la controversia, es decir, el monto de la garantía por adelanto de materiales, supera las 10 UIT.

9. Ahora bien, habiendo sustentado que el presente arbitraje es institucional por mandato legal, es importante remitirnos al literal b) del numeral 226.2 del art. 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, Ley 30225, el cual indica lo siguiente:

Artículo 226. Convenio arbitral

226.1. Cuando corresponda el arbitraje institucional, en el convenio arbitral las partes encomiendan la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral.

226.2. En los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral:

a) Cuando no se ha incorporado un convenio arbitral expreso en el contrato.

b) Cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional no se ha designado a una institución arbitral determinada.

10. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 226.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aplicable, el Consorcio debe iniciar arbitraje en cualquier institución arbitral por disposición normativa. En ese sentido, el Consorcio ejerció válidamente su derecho eligiendo al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD como la Institución Arbitral, donde se realizará el arbitraje, siendo aplicable para tales fines su reglamento de arbitraje y demás normatividad institucional.

11. En segundo lugar, habiendo indicado lo anterior, es importante tener presente que el ANEXO 1 del Reglamento de Arbitraje del Centro – REGLAS DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA, es aplicable y vinculante a las partes por lo dispuesto en los siguientes artículos del reglamento y del propio ANEXO 1 del Reglamento de Arbitraje del Centro – REGLAS DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA:

Centro de Conciliación y Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

REGLAMENTO DE ARBITRAJE:

Artículo 65°.- Medida Cautelar emitida por Árbitro de Emergencia

1. Hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes que requiera medidas cautelares urgentes puede solicitar que se inicie un procedimiento ante un árbitro de emergencia, quien conoce y resuelve la respectiva solicitud
2. Las decisiones adoptadas por el Árbitro de Emergencia son vinculantes para las partes, quienes, por el hecho de haber sometido la controversia a arbitraje bajo el Reglamento, se obligan a cumplirlas sin demora.
3. Se extingue la competencia del Árbitro de Emergencia por la constitución del Tribunal Arbitral.

ANEXO 1 del Reglamento de Arbitraje del Centro – REGLAS DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA

ANEXO I
REGLAS DEL ARBITRAJE DE EMERGENCIA

Artículo 1°.- Árbitro de Emergencia

1. Las partes podrán recurrir a un arbitraje de emergencia por su solo sometimiento al arbitraje institucional administrado y organizado por el Centro; o cuando el convenio arbitral no prohíba expresamente el arbitraje de emergencia.
2. Cualquiera de las partes que se encuentre en situación de urgencia podrá solicitar el nombramiento de un Árbitro de Emergencia para que dicte las medidas correspondientes, de conformidad a lo dispuesto en el presente Reglamento.
3. Se entiende como urgencia, aquella situación que no pueda esperar hasta la constitución del Tribunal Arbitral.
4. El Árbitro de Emergencia será competente hasta producida la constitución del

12. Por lo indicado anteriormente, toda ves que existe un sometimiento al arbitraje institucional administrado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD por disposición legal por dos cuerpos normativos, no queda duda alguna que el procedimiento cautelar de emergencia es

vinculante a las Partes y, por ende, las Partes quedan obligadas a cumplir las decisiones y resoluciones emitidas por Árbitro de Emergencia, árbitro que fue designado conforme a la ley peruana antes citada y al propio reglamento de arbitraje de la institución arbitral.

b. <u>Respecto de la naturaleza de la solicitud cautelar de emergencia</u>

13. Como se indicó en la Resolución No. 01 del presente Cuaderno Cautelar de Emergencia, el Árbitro Único realizó un relato y explicación del origen de la figura del árbitro de emergencia, la misma que ha sido concebida con el objeto de que la parte que requiera una medida cautelar urgente y que no pueda esperar hasta la constitución del Tribunal Arbitral, pueda solicitar una medida cautelar antes de la de la constitución del Tribunal Arbitral a un profesional especializado sin tener que recurrir al Poder Judicial.

14. Al respecto, la doctrina peruana señala que muchas instituciones arbitrales a nivel mundial han ido introduciendo en sus reglamentos de arbitraje la figura del árbitro de emergencia como una solución a casos en los cuales una parte necesita una medida de protección antes del inicio del procedimiento arbitral1.

15. Debido a la regulación internacional del árbitro de emergencia, diversos centros de arbitrajes peruanos han incorporado la figura del árbitro de emergencia en sus reglamentos arbitrales, **<u>tal es el caso del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD (en adelante EL REGLAMENTO)</u>** donde se regula al árbitro de emergencia y en el artículo 65º se establece:

> ***Artículo 65º.- Medida Cautelar emitida por Árbitro de Emergencia***
> *1. Hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes que requiera medidas cautelares urgentes puede solicitar que se inicie un procedimiento ante un árbitro de emergencia, quien conoce y resuelve la respectiva solicitud*
> *2. Las decisiones adoptadas por el Árbitro de Emergencia son vinculantes para las partes, quienes, por el hecho de haber sometido la controversia a arbitraje bajo el Reglamento, se obligan a cumplirlas sin demora.*
> *3. Se extingue la competencia del Árbitro de Emergencia por la constitución del Tribunal Arbitral.*
> *4. El derecho de las partes de recurrir a un Árbitro de Emergencia no impide que cualquiera de ellas pueda solicitar a la autoridad judicial competente que dicte medidas cautelares.*

1 EZCURRA Huáscar y OLORTEGUI Julio; Litigio Arbitral: el arbitraje desde otra perspectiva; Editorial Palestra; Lima – 2016; p.p. 195.

16. Ahora, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 3.6 del ANEXO 1 del Reglamento de Arbitraje del Centro – REGLAS DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA, cuando el Árbitro de Emergencia corra traslado de la solicitud cautelar a la contraparte, vencido el plazo otorgado, con o sin la absolución, se deberá resolver el pedido cautelar en un plazo máximo de 2 días.

> **Artículo 3°.- Nombramiento**
>
> 1. El Consejo Superior de Arbitraje nombra a un Árbitro de Emergencia seleccionado entre los que integran el Registro de Árbitros del Centro en el plazo de un (01) día hábil luego de comunicada la admisión a trámite de la solicitud.
> 2. Una vez nombrado el Árbitro de Emergencia, la Secretaría le remite los antecedentes de la solicitud de medidas de emergencia.
> 3. El Árbitro de Emergencia designado deberá remitir su aceptación o declinación al cargo en un plazo de hasta un (01) día hábil. Con la aceptación de la designación se considera constituido el Árbitro de Emergencia.
> 4. Conjuntamente con su aceptación, el Árbitro de Emergencia deberá pronunciarse sobre la necesidad o no de poner en conocimiento la solicitud de Medida de Emergencia a la contraparte, en caso corresponda.
> 5. En caso de resolverse la medida sin conocimiento de la contraparte, el Árbitro de Emergencia, cuenta con un plazo de dos (02) días hábiles para emitir la Resolución correspondiente al pedido de medida de emergencia.
> 6. Si el Árbitro de Emergencia decide que la medida debe ser tramitada con conocimiento de la contraparte, se correrá traslado a fin de que dicha parte se pronuncie en un plazo de hasta dos (02) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, con la absolución de la contraparte o sin ella, el árbitro deberá resolver el pedido cautelar presentado; en un plazo máximo de dos (02) días hábiles.

17. Por lo tanto, lo indicado anteriormente evidencia la naturaleza de urgente del procedimiento cautelar de emergencia regulado en el ANEXO 1 del Reglamento de Arbitraje del Centro – REGLAS DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA. Por lo tanto, el Árbitro Único está obligado a dar trámite célere del pedido cautelar de emergencia, considerando los plazos máximos previstos en el art. 3 del ANEXO 1 del Reglamento de Arbitraje del Centro – REGLAS DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA.

c. <u>Respecto del inminente riesgo de ejecución de la garantía</u>

18. El análisis del Árbitro Único no puede escapar a las circunstancias de urgencia que motivan la presentación de una solicitud cautelar de emergencia. En el presente caso, se ha tomado conocimiento del inicio de un procedimiento de ejecución de la **POLIZA DE CAUCION No. 0001959-5,** emitida por CRECER SEGUROS, por el importe de S/. 1'333,052.60 (un millón

trecientos treinta y tres mil cincuenta y dos con 60/100 soles) que garantiza la entrega del adelanto de materiales derivado del CONTRATO No. 0326-2020-MD.ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA, mediante el escrito presentado por el Consorcio el 12 de mayo de 2023.

19. Al respecto, dicha situación motiva al Árbitro de Emergencia emitir un pronunciamiento sobre la petición de medida cautelar de emergencia de forma célere y dentro del plazo previsto en el art. 3.6 del ANEXO 1 del Reglamento de Arbitraje del Centro – REGLAS DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA.

20. Por lo tanto, las circunstancias antes mencionadas y el riesgo de la consumación del petitorio de la solicitud cautelar de emergencia, al emitirse una decisión cautelar con posterioridad a la ejecución de la garantía objeto de la petición cautelar de emergencia, motiva al Árbitro de Emergencia proceder a emitir pronunciamiento sobre la solicitud cautelar sin correr traslado al Consorcio de la oposición formulada por la Entidad, considerando además que dicho procedimiento no se encuentra regulado en el ANEXO 1 del Reglamento de Arbitraje del Centro – REGLAS DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

d. <u>Aplicación de un análisis de proporcionalidad</u>

21. El derecho a la motivación de decisión es un derecho derivado del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Por lo tanto, es fundamental para el Árbitro de Emergencia por lo que, como una garantía de la motivación de la presente decisión, además de considerar la aplicación de las fuentes de derecho aplicables al presente caso, como son las normas de contratación publica y la ley de arbitraje peruana, se ha considerado realizar un análisis de proporcionalidad de la decisión de emitir un pronunciamiento sin traslado de la oposición formulada por la Entidad.

22. Sobre el particular el test de proporcionalidad es un instrumento metodológico originado en tribunales constitucionales europeos que se emplea para medir si el grado de limitación de un derecho por una decisión de un tribunal, en este caso de un árbitro de emergencia, el cual debe ser compatible con la normatividad aplicable y la propia constitución, atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad de la afectación al derecho. Por ello, el Tribunal Constitucional peruano utiliza este mecanismo para ponderar casos de conflictos entre derechos.

23. Al respecto, Test de Proporcionalidad apela a tres sub principios: IDONEIDAD, NECESIDAD y PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO o PONDERACIÓN, de una decisión en la que se pondere un derecho sobre otro. En el presente caso, se encuentra en análisis el derecho del Consorcio a absolver la

oposición formulada por la Entidad y de otro lado, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en este caso, a la obtención de una decisión cautelar de emergencia efectiva y oportuna.

24. Sobre el particular, la idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin entre el medio adoptado y el fin medio a fin, entre el medio adoptado y el fin propuesto. Es decir, se trata del análisis de una relación medio-fin (STC N° 0045-2004-AI). En el presente caso, resulta idóneo atender de forma célere y sin correr traslado al Consorcio la oposición formulada por la Entidad a fin de garantizar que la decisión cautelar sea emitida de forma oportuna y antes de una eventual ejecución de la garantía que haga no efectiva la tutela cautelar del Consorcio.

25. Respecto del principio de necesidad, esta busca examinar si existen otros medios alternativos al optado que no sean gravosos o al menos que lo sean optado que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata del análisis de una relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el optado y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptarse para alcanzar el mismo fin. (STC N° 0045-2004-AI). En el presente caso, dadas las circunstancias antes descritas y que el art. 3.6 del ANEXO 1 del Reglamento de Arbitraje del Centro – REGLAS DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA no prevé un procedimiento y plazo para la absolución de oposiciones formuladas en el procedimiento cautelar de emergencia, el Árbitro de Emergencia advierte que no existe otra alternativa menos gravosa al derecho a la tutela cautelar efectiva en el presente caso, teniendo el riesgo de caer en no efectiva la decisión y el propio procedimiento si se llegara a ejecutar la garantía antes de emitirse una decisión sobre el pedido cautelar.

26. Finalmente, respecto del principio de proporcionalidad en sentido estricto, consiste en una comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en el derecho. La comparación de estas dos variables ha de efectuarse según la denominada ley de ponderación: "Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro". Como se aprecia, en la ley están presentes los dos elementos: la afectación –o no realización– de un principio y la satisfacción -o realización- del otro del otro.

27. Se establece así una relación directamente proporcional según la cual: cuanto mayor es la intensidad de la intervención o afectación del derecho, y por tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización del fin constitucional. Si esta relación se cumple, entonces, la intervención en el derecho habrá superado el examen de la ponderación y no será inconstitucional; por el contrario, en el supuesto de que la intensidad de la afectación en el derecho sea mayor al grado de realización del fin

constitucional, entonces, la intervención en el derecho no estará justificada y será inconstitucional (STC N° 0045-2004-AI).

28. Al respecto, en el presente caso existe un mayor grado de realización u optimización de la tutela jurisdiccional (cautelar) efectiva del Consorcio en comparación de la afectación al derecho de absolución de la oposición, toda vez que la consecuencia sería la inefectividad del propio procedimiento cautelar y de la decisión cautelar misma en caso se ejecute la garantía objeto de la petición cautelar de emergencia.

29. En consecuencia, de lo indicado anteriormente, el Árbitro de emergencia deja constancia que la decisión ha superado el test de proporcionalidad, motivándose, adicionalmente en la normatividad aplicable al Contrato y al arbitraje.

30. Por lo anterior, el Arbitro de Emergencia, procede a resolver la oposición formulada por la Entidad.

e. <u>Pronunciamiento sobre la oposición formulada por la Entidad</u>

31. Sobre el particular, el Árbitro de Emergencia cumple con precisar que es incorrecto afirmar que el presente procedimiento cautelar de emergencia se encuentre regulado por el Reglamento de Arbitraje de la Corte internacional de Arbitraje como indica la Entidad, toda vez que el Árbitro de Emergencia, solo invocó el art. 29 de dicho reglamento para brindar una explicación del origen del procedimiento cautelar de emergencia. Por ello, confirma que la normatividad aplicable al presente procedimiento es la Ley de Arbitraje peruana, D.L. 1071, la Ley de Contrataciones y su Reglamento y el Reglamento de Arbitraje del Centro, así como sus anexos y demás ordenamiento institucional.

32. Por lo indicado anteriormente, el Árbitro de Emergencia considera que la Entidad ha cometido un error al considerar que el Reglamento de Arbitraje de la Corte internacional de Arbitraje era aplicable al presente caso. En consecuencia, no existe irregularidad e ilegalidad alguna.

33. Finalmente, el Árbitro de Emergencia deja constancia que la Entidad solo ha formulado una oposición por la presunta aplicación del Reglamento de Arbitraje de la Corte internacional de Arbitraje, no habiéndose formulado alguna oposición a la competencia de la Institución Arbitral y del propio Árbitro de Emergencia, quedando pleno consentimiento de dichas competencias.

34. Por lo indicando anteriormente, el Árbitro de Emergencia declara infundada la oposición formulada por la Entidad.

II. RESPECTO DE LA SOLICITUD CAUTELAR DE EMERGENCIA

a. Marco Teórico sobre la solicitud cautelar de emergencia.

35. La Medida Cautelar debe ser adecuada a la naturaleza de la pretensión, también debe estar premunida de razonabilidad y utilidad, pues la actividad cautelar responde al principio de la mínima injerencia, que impone evitar los perjuicios innecesarios al presunto deudor u obligado; de ahí que, una de las reglas a considerar en la cautela debe ser que el acreedor no puede exigir que la resolución cautelar recaiga y/o afecte bienes con perjuicio grave para el deudor, si hubiera otros disponibles. En suma, a través de esto se busca crear un equilibrio entre el interés del acreedor con la cautela y los efectos de esta afectación frente al presunto deudor; esta ponderación se realiza en búsqueda del equilibrio, lleva trabajar la idea de proporcionalidad entre la magnitud de la afectación con la cobertura del derecho que se quiere asegurar.

36. Por otra parte, es preciso señalar que, para otorgar una medida cautelar, la parte que lo solicita debe demostrar: ***(i)*** la apariencia del derecho invocado ó ***"fumus boni iuris"***, ***(ii)*** un real peligro de irreparabilidad en la demora o ***"periculum in mora"*** y; ***(iii)*** la adecuación del pedido cautelar. Que, sobre la Verosimilitud del derecho, debemos considerar a lo aparente, es decir, a la probable existencia de un derecho, del cual se pide o se pedirá, tutela en el proceso principal. Para esto, señala Liebman[2], no se trata de establecer la certeza de la existencia del derecho, que es propiamente el objeto del proceso principal, sino de formular un juicio de probabilidad de su existencia sobre la base de una cognición sumaria y superficial, - prima facie - ya que el análisis detenido y riguroso se realizará al interior del proceso principal en el cual las partes ejercitaran sus derechos en los estadios correspondientes.

37. Asimismo, y no obstante lo antes expresado, pese al examen prima facie, debe tenerse en cuenta que, para el caso de medidas cautelares emitidas por los árbitros, generalmente, la parte contraria a la solicitante es informada y consultada acerca de la medida cautelar solicitada por lo que el grado de cognición de los árbitros de los hechos y términos de la pretensión cautelar son percibidos desde los dos puntos de vista que se presentan en la contienda arbitral, sin que eso signifique que el análisis tenga un carácter distinto al que produce un análisis prima facie. En esa misma línea, la verosimilitud del derecho invocado no supone un convencimiento pleno o certeza del juzgador de lo alegado sino, simplemente –de acuerdo con la Doctrina autorizada-, que tenga una apariencia de verdadero o, como dice, Piero Calamandrei, una "*hipótesis*" razonable, sujeta al examen y decisión que deberá tomar el árbitro en el laudo, el conocimiento sumario de los hechos y de las causas que motivan el pedido cautelar que de modo

[2] **LIEBMAN Enrico (1980)** *Manual de Derecho Procesal Civil*, Ediciones Jurídicas Europa –América, Buenos Aires, Pág. 162.

solvente sustente dicho pedido. Asimismo, lo verosímil ha de ser el derecho, que el invocado por quien pide la medida, aparezca a la luz de la razón como posiblemente cierto, es decir, conllevando por su contundencia, la virtud de ser reconocido por un juicio de certeza si se confirman durante el pleito los elementos que se observan al tiempo de formular el juicio de verosimilitud.

38. Que, en consecuencia, como dicen algunos autores, esa verosimilitud consiste en un ***"fumus iuris boni"***, un mero "*humo de buen derecho*", en otras palabras, que la demanda debe tener un viso de razonabilidad, aunque sea tenue y evanescente como el humo; es decir, lo que se exige es que, no se pueda considerarse a los solicitado, prima facie, como un pedido estrafalario o absolutamente ajeno a Derecho. En otras palabras, lo posible es lo que, es admitido como susceptible de darse en la realidad; el derecho será verosímil si es probable que exista, y lo probable es lo que se puede demostrar mediante a comprobación de los hechos. En cuanto al peligro en la ***demora "Periculum in mora"*** constituye un elemento importante a tomar en cuenta en el estudio de la medida cautelar. Vale decir, requiere ser alegado y justificado, más no probado. Al respecto, Barrios De Angelis, citado por Ledesma Narváez ([3]), advierte que, todo el fenómeno no determina un peligro actual para que el objeto del proceso se modifique, por causa externa o interna, antes de que las funciones principales se hallen en estado de transformarlo; o que el peligro actual vierta sobre la alteración de los medios de instrucción, por causa interna sumada a la falta de instantaneidad del proceso. En ambos casos se tiene en cuenta el daño previsible para la plena eficacia de las funciones ejercidas en el futuro. Ahora bien, Liebman, indica que para innovar el peligro basta señalar un fundado temor que mientras se espera aquella tutela, lleguen a faltar o alterar las circunstancias de hecho favorables a la tutela misma, esto implicada que el peligro en el demora habrá de ser apreciado con relación a la urgencia en obtener protección especial, dados los hechos indicativos de la irreparabilidad o el grave daño que puede significar esperar al dictado del laudo; de allí que, la medida cautelar no solo busque garantizar sino anticipar los efectos de dicho fallo.

39. En ese sentido, la posibilidad de peligro señalada por el Consorcio es igualmente verosímil en el sentido antes indicado de esta palabra, puesto que el no ampararla podría provocar un daño que finalmente pueda impedir los efectos de la conclusión final del Laudo. Que, por otro lado, no puede exigirse una interpretación restrictiva de los hechos y del derecho en la concesión de medidas cautelares porque, ello sería contrario a la idea de apariencia o "humo" que prima en la naturaleza de esta institución y, por ese camino, atentaría contra el derecho fundamental a la tutela

[3] **LEDESMA NARVAEZ, Marianella**, *Comentarios al Código Procesal Civil*, *Tomo III*, Ed. Gaceta Jurídica, Pág. 28.

jurisdiccional efectiva, ya que la función de solución de conflictos quedaría desnaturalizada si los laudos no pueden hacerse efectivos en la práctica. Que, en atención a lo anterior, en casos de duda debe resolverse a favor de la concesión de la medida cautelar, teniendo en cuenta que, a opinión de este colegiado, debido a la naturaleza variable de las medidas cautelares, éstas siempre pueden ser sustituidas y/o modificadas cuando el afectado ofrezca garantía suficiente.

Posición del Árbitro Único ante los argumentos de las partes.

b. <u>Apariencia de derecho:</u>

40. En cuanto a la apariencia de derecho, se identifica que la Litis (en base a las pretensiones de la futura demanda) se compone y desarrolla en dos aspectos marcados estos son: la resolución contractual determinada por la Entidad, a través de la cual manifestó su voluntad de dar por concluido el contrato; y el otro aspecto, se refiere a los efectos jurídicos de dicha resolución, como lo puede ser la ejecución de garantías.

41. Cabe precisar que el Consorcio alega que la Resolución de Alcaldía No. 062-2023-MDA/A del 06 de febrero de 2023 no ha cumplido con el procedimiento de resolución previsto en el art. 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, siendo, bajo su postura, ineficaz. En consecuencia, de ello, la Entidad no estaría habilitada a ejecutar garantía alguna.

42. Por su parte la Entidad, alude fundamentalmente que con Carta Notarial No. 006-2023-MDA/GM de fecha 07 de marzo de 2023, se notificó la Resolución de Alcaldía No. 062-2023-MDA/A del 06 de febrero de 2023 a través de la cual se comunica la resolución del Contrato y requiere al Contratista la devolución del saldo por amortizar el adelanto de materiales bajo apercibimiento de la ejecución de la carta fianza en un plazo de 10 días.

43. Al respecto, dicho plazo concedido ha vencido, correspondiendo la aplicación del art. 155.2 y el literal d) del numeral 155.1 del art. 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la cual dicta que la garantía por adelantos se ejecuta como consecuencia de la resolución del contrato, aún cuando dicho evento haya sido controvertido.

44. Sobre el particular, el Árbitro de Emergencia estima que la apariencia de derecho se sostiene en la validez de la resolución del Contrato y sus efectos. Al respecto, el Árbitro de Emergencia advierte que la obligación de devolución del adelanto de materiales a través del pago, normado en los numerales 1, 2 y 3 del art. 155, solo puede ser determinada cuantitativamente a través de un cálculo matemático objetivo. Sin embargo, en el presente caso el Árbitro de Emergencia advierte que el

monto del saldo por amortizar del adelanto de materiales de acuerdo a la Entidad es de S/ 1'286,136.00, sin embargo, la cobertura de la POLIZA DE CAUCION No. 0001959-5, emitida por CRECER SEGUROS, es por el importe de S/. 1'333,052.60 (un millón trecientos treinta y tres mil cincuenta y dos con 60/100 soles).

45. La diferencia cuantitativa antes descrita evidencia que no existe coherencia ni consistencia entre el monto que se pretende ejecutar y el monto de la cobertura de la garantía. Por ello, el Árbitro de Emergencia considera que sin perjuicio que la resolución contractual realizad a por la Entidad no está consentida, pero no es impedimento para ejecutar una fianza por adelanto de acuerdo al art. 155.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la obligación de pago a cargo del Contratista no ha sido determinado y esta es condición para que la Entidad quede autorizada para la ejecución de la fianza.

46. Finalmente, el Árbitro de Emergencia advierte que existe la posibilidad de que se deje sin efecto la resolución de contrato de la Entidad y se tenga que volver a la ejecución del Contrato, supuesto en el cual la ejecución de la garantía generaría una distorsión en la situación de hecho y de derecho en que deben estar las partes

47. Por lo tanto, el Árbitro de Emergencia considera que la definición del monto exacto por ejecutar debe ser fijado por las Partes de forma fehaciente y objetivamente durante el arbitraje o en la etapa de liquidación del Contrato, lo cual podrá ser analizado y resuelto por el árbitro o los árbitros que conozcan del fondo de la controversia; en ese sentido, para este Árbitro Único es real y concreto que de lo argumentado por el Consorcio se configura el *fumus bonnus juris* que se requiere, pues su derecho es posible o probable.

c. <u>Peligro en la demora:</u>

48. Para analizar la concurrencia del presupuesto de **"*peligro en la demora*",** el Árbitro de Emergencia considera pertinente analizar cuál es la posición del solicitante frente a los hechos cuya cautela solicita sea otorgada, se sostiene que el peligro en la demora se configura por el hecho objetivo e inminente de que el efecto de la ejecución de la garantía por adelanto de materiales en el Consorcio significa soportar una sanción desde antes que se haya determinado si existió o no existió base para su ejecución, afectando de esta forma a las personas (jurídicas y/o naturales) que conforman el Consorcio con la disminución de sus patrimonios durante la secuela del proceso arbitral.

49. Adicionalmente, es importante tener presente que el Consorcio ha informado el inicio de un procedimiento de ejecución de la **POLIZA DE**

CAUCION No. 0001959-5, emitida por CRECER SEGUROS, por el importe de S/. 1'333,052.60 (un millón trecientos treinta y tres mil cincuenta y dos con 60/100 soles) que garantiza la entrega del adelanto de materiales derivado del CONTRATO No. 0326-2020-MD.ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA, mediante el escrito presentado por el Consorcio el 12 de mayo de 2023.

50. Por lo tanto, para el Árbitro de Emergencia, la afectación al patrimonio es un hecho positivo, evidenciado en la posible ejecución de la garantía por adelanto de materiales y como se ha señalado considera que basta señalar un fundado temor que mientras se espera aquella tutela, siendo en el presente caso que habiéndose abierto la discusión con este proceso acerca de la validez de los actos de la Entidad en la resolución de contrato que ha efectuado, lo cual le daría derecho a la ejecución de la garantía, la parte peticionante podría sufrir el efecto como si su derecho hubiese sido desestimado, agravándose su posición financiera.

d. <u>Adecuación de la medida cautelar:</u>

51. El Árbitro de Emergencia tiene la facultad de graduar la intensidad del efecto de la medida cautelar, a decir de la doctrina ([4]) *"la alteración de la relación material es una necesidad – en muchos casos- para que la medida cautelar cumpla su finalidad. Sin embargo, esta realidad tiene que ser conjugada con el hecho que el juez debe otorgar aquella medida que afecte lo menos posible los intereses del sujeto sobre quien recae la misma"* y para el efecto aplicar el principio de mínima injerencia.

52. Es por ello que estando a que la pretensión cautelar persigue que evite la ejecución de la garantía de adelanto de materiales se mantenga hasta la decisión final que se emita con el laudo arbitral, el Árbitro de Emergencia estima que el propósito es mantener el estadio que evidencia un equilibrio de la relación contractual afectada por una disputa, para que luego de resuelta esta se pueda proceder a accionar sobre ellas sobre la base del nuevo orden jurídico que instaure el laudo arbitral. Siendo ello el propósito, para el Árbitro resulta adecuado establecer los mecanismos que no puedan alterar los derechos de las partes y en particular de la Entidad, dentro del contexto del proceso arbitral y la determinación de solución de la disputa planteada y que si bien una medida cautelar tiene un efecto directo en la esfera jurídica de quien la padece, esta no afecte de modo que lo ponga en una situación gravosa que desestabilice su posición.

<u>Octavo</u>: En cuanto a la ***caución de la media cautelar*** el Árbitro señala:

[4] **Monroy Palacios, Juan José**. *Bases para la formación de una Teoría Cautelar*. Edit. Comunidad 2002. Pag.187-188.

53. Primero que, conviene en primer lugar tratar el punto de lo regulado por el Decreto de Urgencia N° 20 – 2020 modificatorio del Decreto Legislativo 1071 que norma el arbitraje y que dispone, que cuando el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar, se exige como contra cautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada, no pudiendo ser el monto de la caución, menor a la garantía de adelanto de materiales del contrato (disposición normativa similar se ha establecido en la Ley N° 31589).

54. Ante la premisa planteada el Árbitro de Emergencia advierte que, estamos frente una norma que establece una condición diferenciada exorbitante respecto de los demás usuarios del arbitraje y que, por lo tanto, colisiona con el ordenamiento legal de tutela. Ante ello es preciso considerar el ejercicio del control difuso, sistema de control constitucional jurisdiccional mediante el cual los jueces tienen la facultad de inaplicar una norma de inferior jerarquía ante su incompatibilidad con el texto constitucional.

55. En efecto, el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional desarrolla meridianamente el control difuso e interpretación constitucional. En el caso, el solicitante de la medida cautelar ha indicado que debe aplicarse el control difuso por ser el Decreto en cuestión inconstitucional pues este vulneraría los derechos fundamentales de igualdad, tutela jurisdiccional efectiva y el principio de razonabilidad.

56. Ante lo expuesto el Árbitro de Emergencia, de acuerdo a doctrina autorizada y a los precedentes existentes del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad que en sede jurisdiccional arbitral se ejerza control difuso de constitucionalidad de las normas, se avoca al examen de inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia N° 20 – 2020 en el extremo correspondiente. ([5])

57. En el orden expuesto cabe ahora señalar que, los árbitros pueden ejercer el control difuso, entendido como el poder-deber de inaplicar una norma legal contraria a la Constitución, teniendo como fundamento los principios de independencia y unidad de la función jurisdiccional. Esto, como lo expresa el propio Tribunal Constitucional, no implica que la administración de justicia sea exclusiva del Poder Judicial, pues dicha facultad, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, la ejercen también los árbitros, de manera que los órganos que administren justicia, sin excepción, posean las garantías propias de todo órgano jurisdiccional.

[5] El Tribunal Constitucional se ha pronunciado acerca de la facultad de los árbitros para aplicar el control difuso y se advierte ello de Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. 00142-2011-PA/TC, Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Sociedad Minera de Responsabilidad Ltda. María Julia contra la resolución expedida por la tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.

58. Pues bien, en efecto, las exigencias diferentes y más gravosas que exige el Decreto en cuestión a los particulares en los procesos arbitrales con el Estado en comparación de las garantías aplicables a las medidas cautelares en los procesos arbitrales entre particulares, todo ello sin que exista argumento razonable para esa diferenciación, contraviene en efecto el principio de igualdad ([6]). Si bien es innegable que, en contratación pública existe un régimen legal exorbitante para los particulares contratistas del Estado en atención a los intereses públicos a los que se debe el Estado y que están contenidos en la Ley, debe decirse que este régimen legal expreso de prerrogativas públicas debe estar limitado, en primer lugar, por sistematización y especialización, a la Ley de Contrataciones del Estado misma o su Reglamento y no estar contenido en el régimen general de arbitraje; pero, además y sobre todo, esas ventajas públicas deben limitarse a la fase de ejecución de los contratos y no al régimen procesal de la solución de controversias que impone un tratamiento igualitario a las partes que contienden en un proceso, no existiendo razones legales suficientes para ello expresadas en el Decreto de Urgencia en cuestión y que puedan contradecir ni justificar el dispositivo del citado.

59. No deben ser admisibles ventajas públicas procesales capitales y exorbitantes que limiten los derechos de la parte privada sin ninguna justificación válida, más aún si existen ya disposiciones procesales de por si inequitativas en torno a los embargos contra el Estado o a procedimientos específicos de ejecución de laudos sujetos a disponibilidad presupuestal.

60. Por otro lado, la exposición de motivos del Decreto de Urgencia que alude a abusos en la admisión de cauciones juratorias como garantías de posibles daños causados por medidas cautelares otorgadas a los particulares en las controversias provenientes de contratos estatales, así como la disposición misma de exigirse una caución del 10% del contrato como mínimo, conlleva una restricción sustancial de la garantía constitucional a una debida tutela jurisdiccional exorbitando en grado tal el régimen - comparándolo con los arbitrajes en donde no interviene el Estado y, también, con las controversias en sede judicial - , que en muchos casos sería altamente desproporcionado e irracional que los particulares asuman dicha garantía.

61. En la práctica, sin que exista análisis del juzgador respecto del caso, se exigirá universalmente una garantía que en algunos casos alcanza el equivalente al 100% del monto de la medida cautelar (el monto de la garantía es del 10% del contrato y el de la caución mínima también) y en otra puede fácilmente superar varias veces el monto de lo reclamado.

[6] El artículo 2 de la Constitución consagra el principio de igual ante la ley y así lo reconoce la STC N° 02835-2010-PA/TC, en una de sus considerandos estima que "[...] toda persona tiene derecho [...] a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole"

62. En el presente caso la medida cautelar solicitada está referida a la no ejecución de la garantía de adelanto de materiales, por lo que resultaría desproporcional y contraria al principio de razonabilidad si se exigiera para ello un monto equivalente al 10% del contrato. Resulta evidente que, la exigencia de una contracautela equivalente al 100% de la garantía de adelanto de materiales, hace notoria la desigualdad de trato contenido en el Decreto de Urgencia, e impactaría directamente en contra del derecho de tutela jurisdiccional que se ha solicitado.

63. Asimismo, debe considerarse que el Árbitro Único no observa la necesidad de que se constituya de una contracautela, toda vez que para ello ya se cuenta con la POLIZA DE CAUCION No. 0001959-5, emitida por CRECER SEGUROS, por el importe de S/. 1'333,052.60 (un millón trecientos treinta y tres mil cincuenta y dos con 60/100 soles). En ese sentido, resulta suficiente que se requiera una caución juratoria, considerando que el Consorcio tiene la obligación legal de mantener vigente la renovación de la POLIZA DE CAUCION No. 0001959-5, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, la medida cautelar se considere automáticamente levantada.

En conclusión el Árbitro Único considera que, en el presente caso y sin que ello implique pronunciamiento sobre el fondo del asunto, dada la naturaleza temporal y variable de la decisión cautelar, **(a)** la pretensión del Consorcio tiene apariencia de derecho y no puede ser descalificada de plano por falta de fundamento alguno y **(b)** el peligro que se indica es también verosímil, puesto que podría presentarse un real peligro de no amparar la pretensión en cuestión, antes de que se expida el correspondiente laudo arbitral. Que, en estas circunstancias, si el Árbitro Único no concede la medida cautelar solicitada, existe la posibilidad de que, si el laudo es favorable al Consorcio, éste no pueda ser hecho efectivo en la realidad, debido a que por la demora en el proceso el daño hipotético podría convertirse en real e irreparable.

Que, por estas razones, el Árbitro Único considera que se le debe conceder al Consorcio la **medida cautelar solicitada en los términos que se mencionan en la parte resolutiva.** -

En ese sentido y por las consideraciones antes expuestas el Árbitro de Emergencia.

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la oposición formulada por la Entidad.

SEGUNDO: CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR, conforme a las siguientes instrucciones:

A) DISPÓNGASE que la Municipalidad Distrital de Anchihuay se encuentra impedida de ejecutar la **POLIZA DE CAUCION No. 0001959-5**, emitida por CRECER SEGUROS, por el importe de S/. 1'333,052.60 (un millón trecientos treinta y tres mil cincuenta y dos con 60/100 soles) que garantiza la

entrega del adelanto de materiales derivado del CONTRATO No. 0326-2020-MD.ANCH-UNIDAD DE LOGISTICA.

B) DISPÓNGASE que el Consorcio Vial Ayacucho mantenga la vigencia de la **POLIZA DE CAUCION No. 0001959-5**, debiendo informar de su renovación a la Entidad previamente a su vencimiento, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, la medida cautelar se considere automáticamente levantada.

C) DISPÓNGASE que el Consorcio Vial Ayacucho cumpla con presentar una caución juratoria por el monto de la **POLIZA DE CAUCION No. 0001959-5** con firma de su representante legalizada notarialmente en un plazo de tres (3) días hábiles de notificada la presente medida cautelar.

D) DISPÓNGASE que la presente resolución se notifique a CRECER SEGUROS.

TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes y a CRECER SEGUROS.

LUIS PUGLIANINI GUERRA
ÁRBITRO ÚNICO